

1500388-90.2022.8.26.0571

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca

Comarca: Itapetininga

Foro: Foro de Itapetininga

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... a informação da ocorrência de tráfico em frente ao COFESA. No local, viu três indivíduos. Dois correram e um permaneceu. Este dispensou a droga no chão. Ele trazia dinheiro consigo. Como se vê, a prova é firme ao incriminar o acusado. Registre-se que todas as provas produzidas durante a instrução processual evidenciam que o acusado praticou os crimes descritos na denúncia. As ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapetininga

Foro de Itapetininga

2ª Vara Criminal

Avenida Peixoto Gomide, centro, Itapetininga - SP - cep 18200-160

TERMO DE AUDIÊNCIA - VIDEOCONFERÊNCIA

Processo nº:

1500388-90.2022.8.26.0571 - Controle 2022/001472

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO MACIEL FERREIRA

Data da Audiência:

06/12/2022

Iniciados os trabalhos por videoconferência, com concordância das partes, verificou-se a presença do Exmo. Sr. Dr. Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca, MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal de Itapetininga, dos representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública. Ausente o acusado Bruno Maciel Ferreira, tendo sido decretada sua revelia às fls. 183. Antes de serem inquiridas as testemunhas foram devidamente advertidas acerca da incomunicabilidade. Foi ouvida a testemunha Márcio Ferreira arrolada pelas partes. A Acusação e a Defesa desistiram da oitiva da testemunha Márcio Roberto da Silva Queiroz, o que foi homologado pelo MM. Juiz. O depoimento foi registrado pelo sistema Microsoft Teams. Pelas partes foi dito que não tinham diligências a requerer. Pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi dito que: Não havendo mais provas a serem colhidas, declaro encerrada a instrução, determino as partes que passem aos debates. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, foi dito: MM. Juiz, O réu foi denunciado e está sendo processado como incurso artigo 28, "caput", da Lei 11.343/06, pois, no dia 17 de março de 2022, às 16h50min, na Avenida Peixoto Gomide, nº. 395, Centro, nesta cidade e Comarca de Itapetininga/SP, trazia consigo, para fins de uso pessoal e sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 05 (cinco) pedras de crack, com massa bruta de 4,24g (quatro gramas e vinte e quatro centigramas), substância capaz de determinar a dependência física e psíquica. A denúncia foi recebida em 19/09/2022 (fls. 158). O réu foi pessoalmente citado (fls. 167). Resposta escrita à acusação devidamente apresentada (fls. 171/173). Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas. O réu não foi interrogado. É este o breve relatório. Penso que a ação deve ser julgada procedente. A materialidade está comprovada pelo laudo químico-toxicológico (fls. 66/69) e pelo auto de exibição e apreensão (fls. 04). Certa a autoria. Vejamos. Em solo policial, o réu confessou o

porte de drogas para consumo próprio (fls. 13). Em Juízo, optou pela revelia. A prova oral é suficientemente segura ao incriminá-lo. De fato, diz a denúncia que, após receberem denúncia de que indivíduo do sexo masculino, trajando bermuda e camiseta clara com logotipo da "Lacoste" e boné cor branca, estaria na praça da Bíblia, nas proximidades das "Três escolas", realizando o comércio ilícito de entorpecentes, policiais militares diligenciaram no sentido de apurar tal denúncia. No local dos fatos, visualizaram indivíduo com as mesmas características mencionadas acima, na companhia de outros dois, razão pela qual resolveram abordá-los, ocasião em que, ao perceberem a presença policial, os terceiros se evadiram. Ocorre que o denunciado, tentando evitar a abordagem, desfez-se de substância que trazia consigo, lançando-a ao chão. Em busca pessoal, localizaram em sua posse 05 (cinco) pedras de crack. Realizada a perícia, constatou-se e confirmou-se a sua natureza ilícita. Questionado, o denunciado confirmou que o entorpecente lhe pertencia e que se destinava a consumo próprio. Pois bem. Agora, o policial Márcio Ferreira disse que patrulhava pelo centro, quando receberam a informação da ocorrência de tráfico em frente ao COFESA. No local, viu três indivíduos. Dois correram e um permaneceu. Este dispensou a droga no chão. Ele trazia dinheiro consigo. Como se vê, a prova é firme ao incriminar o acusado. Registre-se que todas as provas produzidas durante a instrução processual evidenciam que o acusado praticou os crimes descritos na denúncia. As palavras da testemunha foram firmes, harmônicas e coerentes, de modo que merecem todo crédito. Convém destacar que não há qualquer indício de que esteja mentindo para incriminar um inocente. Ademais, o réu confessou os fatos (fls. 13), o que corrobora a versão incriminatória. Dessa forma, a condenação é medida impositiva. Ante o exposto, requer e espera o Ministério Público a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos exatos termos da denúncia. Dada a palavra ao Dr. Defensor, foi dito: MM. Juiz. O acusado foi denunciado como incurso no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06. A ação penal, no entanto, não merece prosperar, pelas razões que seguem. 1- Do art. 28 da Lei de Drogas. Atipicidade da conduta. Inconstitucionalidade e inconvenção do art. 28 da Lei n. 11343/06. Precedentes. O tipo descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/06 viola o direito à intimidade e o princípio da lesividade penal, padecendo de inconstitucionalidade. O inciso X do artigo 5º da Constituição da República assevera que "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação". Assim, por meio deste dispositivo legal, a Constituição atribuiu ao indivíduo liberdade para escolher seu modo de vida. Não é legítima a norma penal, em um Estado Democrático de Direito, que pretenda tutelar a saúde ou integridade de uma pessoa contra sua própria vontade e interesse, sendo tal pretensão intangível ao poder estatal. Só é admissível a intervenção do Direito Penal quando houver lesão concreta ou real, transcendental, grave ou significativa e intolerável ao bem jurídico tutelado. Logo, sob a ótica do princípio da lesividade, não existe crime sem lesão ou perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado, bem como não há crime quando a conduta viola apenas bens jurídicos pessoais, por força da ausência da transcendência da ofensa. Por este motivo, não é admissível a criminalização do porte de drogas para consumo pessoal, pois tal conduta não ultrapassa o âmbito privado do agente. Assim, reside a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas em dois pontos. Primeiro, porque o comportamento previsto no tipo não transcende a esfera pessoal do usuário, violando, assim, sua intimidade (vida íntima) e privacidade (autonomia privada) e ferindo, dessa forma, o princípio da transcendência. Em segundo lugar, a conduta prevista no tipo viola o princípio da lesividade, porque não há lesão ou perigo concreto a bem jurídico. Foi reconhecida a repercussão geral sobre o tema "tipicidade penal do porte de droga para consumo pessoal" no julgamento, pelo STF, do Recurso Extraordinário n. 635.659. O julgamento do recurso ainda não foi concluído, mas o Min. Gilmar Mendes, relator, declarou a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas sem redução de texto, votou pela descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal, mas mantendo as sanções previstas no dispositivo legal, conferindo-lhes natureza exclusivamente administrativa. Pelo mundo, as experiências descriminalizadoras são positivas. Os países que adotaram a

descriminalização do consumo de entorpecentes observaram uma redução no índice de consumo e é chegado, portanto, o momento de o Brasil adequar-se ao paradigma contemporâneo para o tratamento do tema. Assim, considerando a evidente inconstitucionalidade do dispositivo, o acusado deve ser absolvido, nos termos do art. 386, III do CPP. 2- Da dosimetria da pena. Na hipótese de eventual desfecho condenatório da ação penal em apreço, requer seja aplicada a pena de advertência, prevista no inciso I do art. 28 da Lei de Drogas, dando-se a pena por cumprida. Por fim, requer seja concedido ao réu o direito de apelar em liberdade, já que não há razões neste momento para a decretação pela custódia cautelar. Na sequência, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: Vistos. BRUNO MACIEL

FERREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 28, "caput", da Lei n. 11.343/2006, porque, em 17 de março de 2022, por volta das 16 h e 50 min, na Av. Peixoto Gomide, n. 395, centro, nesta Cidade e Comarca, trazia consigo, para uso próprio, cinco pedras de "crack", com peso de 4,24 gramas, substância entorpecente causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. A denúncia foi recebida, fls. 158, e o Réu citado, fls. 167, respondeu a acusação por intermédio da Defensoria Pública, fls. 171/173. Nas fls. 183 foi decretada a revelia do Réu. Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes (audiência por videoconferência). Em alegações finais o Dr. Promotor de Justiça pediu a condenação do Réu; por outro lado, a Defesa insistiu na absolvição. É o relatório. I - FUNDAMENTO. A ação penal é procedente. Às fls. 04 foi juntado o Auto de Exibição e Apreensão no qual consta: R\$ 65,00 e cinco pedras de "crack", com peso de 4,24 gramas. Às fls. 66/69 foi juntado o Laudo Pericial de Exame Definitivo de Entorpecente n. 85.405/2022 no qual apontou: "Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em Camada Delgada e foi DETECTADA presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores". Márcio Ferreira, Testemunha, disse que estava em patrulhamento quando recebeu denúncia de tráfico de entorpecentes, foi ao local e viu três pessoas, duas das quais saíram e o Réu permaneceu, tendo jogado algo ao chão; fez a abordagem e encontrou, com o Acusado, R\$ 65,00, e, no chão, cinco pedras de "crack". Confrontando-se a prova coligida infere-se que o Réu foi visto quando trazia consigo 05 porções de "crack"; tentou ludibriar os policiais ao jogar as drogas ao chão, o que visto por eles, que fizeram a apreensão do entorpecente. Pela quantidade apreendida e ausentes observações de venda, verifica-se a destinação pessoal. Confirmada a suficiência das provas, não merece prosperar a tese da atipicidade da conduta, pois, apesar de ter se operado a despenalização da conduta de porte de drogas para consumo próprio, não ocorreu a sua descriminalização. O artigo 28 da Lei n.º 11.343/06 não prevê em seu preceito secundário qualquer pena privativa de liberdade, mas prevê sanções de outra natureza, logo houve mera despenalização,

conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal em Questão de Ordem: "I. Posse de droga para consumo pessoal: (art. 28 da L. 11.343/06 - nova lei de drogas): natureza jurídica de crime. 1. O art. 1º da LICP - que se limita a estabelecer um critério que permite distinguir quando se está diante de um crime ou de uma contravenção - não obsta a que lei ordinária superveniente adote outros critérios gerais de distinção, ou estabeleça para determinado crime - como o fez o art. 28 da L. 11.343/06 - pena diversa da privação ou restrição da liberdade, a qual constitui somente uma das opções constitucionais passíveis de adoção pela lei incriminadora (CF/88, art. 5º, XLVI e XLVII). 2. Não se pode, na interpretação da L. 11.343/06, partir de um pressuposto despreço do legislador pelo "rigor técnico", que o teria levado inadvertidamente a incluir as infrações relativas ao usuário de drogas em um capítulo denominado 'Dos Crimes e das Penas', só a ele (L. 11.343/06, Título III, Capítulo III, arts. 27/30). 3. Ao uso da expressão "reincidência", também não se pode emprestar um sentido "popular", especialmente porque, em linha de princípio, somente disposição expressa em contrário na L. 11.343/06 afastaria a regra geral do C. Penal (C. Penal, art. 12). 4. Soma-se a tudo a previsão, como regra geral, ao processo de infrações atribuídas ao usuário de drogas, do rito estabelecido para os crimes de menor potencial ofensivo, possibilitando até mesmo a proposta de

aplicação imediata da pena de que trata o art. 76 da L. 9.099/95 (art. 48, §§ 1º e 5º), bem como a disciplina da prescrição segundo as regras do art. 107 e seguintes do C. Penal (L. 11.343, art. 30). 6. Ocorrência, pois, de 'despenalização', entendida como exclusão, para o tipo, das penas privativas de liberdade. 7. Questão de ordem resolvida no sentido de que a L. 11.343/06 não implicou abolitio criminis (C. Penal, art. 107). II. Prescrição: consumação, à vista do art. 30 da L. 11.343/06, pelo decurso de mais de 2 anos dos fatos, sem qualquer causa interruptiva. III. Recurso extraordinário julgado prejudicado." (RE 430105 QO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1.ª Turma, DJe. 27.04.2007). "[...] A punição, na hipótese, é de rigor para salvaguardar a sociedade do mal potencial causado pelo porte de droga, apto a ensejar o incremento do tráfico de entorpecentes, a par de outros delitos associados ao uso indevido da droga. Ademais, deve ser ponderado que o E. Supremo Tribunal Federal, a quem compete o controle de constitucionalidade das normas, em momento algum reconheceu a indigitada inconstitucionalidade, razão pela qual o dispositivo de lei há que ser observado e cumprido" (RE 635660 SP, rel. Min. Carlos Ayres Britto, 22.3.2011). Destarte, é impositiva a condenação por incidir o Réu no artigo 28, da Lei n.º 11.343/06. II - DA DOSIMETRIA DA PENA. (Art. 59, inc. II, do Código Penal). Fixada a responsabilidade do Acusado, passo à dosimetria da pena. Atento às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal e aos critérios contidos no artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 aplico ao Réu a pena de advertência. III - DECIDO. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA e o faço para condenar BRUNO MACIEL FERREIRA, qualificado nos autos, a pena de ADVERTÊNCIA, dando-o como incurso no artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/06. Dá-se a pena por cumprida. Sem condenação nas custas. O Réu respondeu em liberdade a este processo e, tendo em vista a pena aplicada, poderá recorrer nessa condição. Sentença publicada em audiência. Cumpra-se. A presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19. O Termo de Audiência ficará disponível no sistema SAJ, ficando os presentes intimados do prazo de 5 (cinco) dias para interposição do recurso da sentença, dispensada a assinatura das partes, por se tratar de processo digital - sistema SAJ (Artigo 1.269 das NSCGJ). Nada Mais. Itapetininga, 06 de dezembro de 2022. Eu, (Marina Alice Correa de Almeida), Escrevente Técnico Judiciário digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA